

刑法

No.95

H21-8

(配点: 3)

月 日

月 日

甲は、道路を通行中、飼い主乙の不注意により乙のもとから逃げ出した犬に足首付近をかみつかれそうになった。このような状況における甲の行為に関する同人の罪責についての次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい（ただし、甲には、各記述に記載された犯罪の故意があるものとする。）。

1. 甲は、逃げ場がなかったことから、犬を足で蹴って怪我をさせた。甲に器物損壊罪が成立する。
2. 甲は、逃げ場がなかったことから、犬を足で蹴ったが、更に犬が甲の足首付近にかみつこうとしたので、近くのA方住居に無断で逃げ込んだ。甲に住居侵入罪は成立しない。
3. 甲は、逃げ場がなかったことから、犬を足で蹴ったが、更に犬が甲の足首付近にかみつこうとしたので、近くにいたBを突き飛ばして身をかわしたところ、それによりBは転倒して頭部を強打したため、脳内出血により死亡した。甲に傷害致死罪は成立しない。
4. 甲は、逃げ場がなかったことから、近くで事態を傍観していた飼い主乙に対し、「犬をおとなしくさせないとお前を殺すぞ。」と怒鳴って脅した。甲に脅迫罪が成立する。
5. 甲は、逃げる余裕があったのにその場にとどまり、たまたま所持していたC所有の傘で犬を強打して怪我をさせるとともに、その傘を壊した。甲に器物損壊罪が成立する。

No95

H21-8

正当防衛・緊急避難

正解

2、5（順不同）

正答率

68%

1 誤っている

261条、36条1項。本記述では、足で蹴って犬を「傷害」した甲の行為は、器物損壊罪（261条）の構成要件に該当する。もっとも、甲に正当防衛（36条1項）が成立すれば、違法性が阻却され、器物損壊罪は成立しないことになるため、正当防衛が成立するかが問題となる。まず、甲が、犬に足首付近をかみつかれそうになったことが「急迫不正の侵害」（36条1項）にあたるかが問題となる。この点、本記述においては、飼い主乙の不注意により乙のもとから逃げ出した犬による侵害であるところ、所有者の過失に基づく人の行為によるものとして、「急迫不正の侵害」にあたることになる。また、犬による傷害を避けるために犬を足で蹴ったことは、自己の身体の安全を「防衛するため」にあたる。更に、甲は、逃げ場がなかったことから、犬を足で蹴って怪我をさせたのであるから、「やむを得ずにした行為」をしたものということができる。よって、本記述における甲には、正当防衛が成立し、違法性が阻却されるから、器物損壊罪は成立しない。

2 正しい

130条前段、37条1項。本記述では、甲はA方住居に無断で逃げ込んでおり、住居侵入罪（130条前段）の構成要件に該当する。もっとも、甲に緊急避難（37条1項）が成立すれば、住居侵入罪は成立しないことになるため、緊急避難が成立するかが問題となる。まず、甲がA方住居に無断で入った行為は、犬が甲の足首付近にかみつこうとしているという「現在の危険」を避けるための行為といえ、逃げ場がなかったということから「やむを得ずにした行為」（37条1項）にあたるといえる。次に、「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」といえるかが問題となる。この点、「程度を超えなかった場合」とは、保全法益と侵害法益とを比較し、後者が前者を越えない限りということの意味する。異種の法益については、それぞれの法益を保護している犯罪の法定刑の軽重が一応の標準となる。ただし、法定刑が必ずしも法益の大小を反映しているとは限らず、また個人法益と各種の公共的法益との関係も明確なものではないため、具体的事例に応じて社会通念に従い法益の優劣を決すべきであるとされている。これは、緊急状態のもとでは、同等又は大なる利益を保護するために同等又は小なる利益を犠牲にすることは許されるとする趣旨に基づくものである。これを本記述についてみると、甲は、自己の身体の安全を保全するため（204条）、Aの住居権を侵害したものであるから、後者が前者を超えないものといえ、「程度を超えなかった場合」ということができる。よって、本記述における甲には、緊急避難が成立するから、住居侵入罪は成立しない。

3 誤っている

205条、37条1項ただし書。本記述では、甲は、Bを突きとばすという暴行（208条）をなし、結果としてBは死亡しているので、甲の行為は傷害致死罪（205条）の構成要件に該当する。もっとも、甲に緊急避難（37条1項）が成立すれば、傷害致死罪は成立しないことになるため、緊急避難が成立するかが問題となる。まず、甲がBを突き飛ばした行為は、逃げ場がなく、犬を足で蹴ったが、更に犬が甲の足首付近にかみつこうとしたためであることから、「自己……の身体に対する現在の危険」を避けるため、やむを得ずにした行為」（37条1項）にあたるといえる。次に、「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」といえるかが問題となる。この点、「程度を超えなかった場合」とは、保全法益と侵害法益とを比較し、後者が前者を越えない限りということの意味する。異種の法益については、それぞれの法益を保護している犯罪の法定刑の軽重が一応の標準となる。ただし、法定刑が必ずしも法益の大小を反映しているとは限らず、また個人法益と各種の公共的法益との関係も明確なものではないため、具体的事例に応じて社会通

念に従い法益の優劣を決すべきであるとされている。これは、緊急状態のもとでは、同等又は大なる利益を保護するために同等又は小なる利益を犠牲にすることは許されるとする趣旨に基づくものである。これを本記述についてみると、甲は、自己の身体の安全を保全するため（204条）、Bの生命を侵害したものであるから、後者が前者を超えるものといえ、「程度を超えなかった場合」ということができない。よって、本記述における甲には、緊急避難は成立しないことから、傷害致死罪が成立する。

4 誤っている

222条1項、36条1項。本記述では、甲は、乙に対し「お前を殺すぞ」と怒鳴り、乙の生命に対し害を加える旨を告知して脅迫しているので、脅迫罪（222条1項）の構成要件に該当する。もっとも、甲に正当防衛（36条1項）が成立すれば、脅迫罪は成立しないことになるため、正当防衛が成立するかが問題となる。まず、甲が犬に足首付近をかみつかれそうになったことが「急迫不正の侵害」（36条1項）にあたるかが問題となるが、これは、飼い主乙の不注意により逃げ出した犬による侵害であり、所有者の過失という人の行為に基づくものであるので、「急迫不正の侵害」にあたることになる。次に、甲は、逃げ場がなかったことから、近くで事態を傍観していた飼い主乙に対し、「犬をおとなしくさせないとお前を殺すぞ。」と怒鳴って脅したものであるところ、自己の身体の安全を「防衛するため」の行為であったとしても、「やむを得ずした行為」をしたものといえるかが問題となる。この点について、「やむを得ずした行為」とは、防衛行為は侵害を排除するために必要な限度であること、及びその行為は、自己又は他人の権利を防衛する手段としての法益侵害・危険が最小限度のものであることを要件とすべきとされている（防衛行為の相当性）。これは、正当防衛の場合には不正対正の関係に基づいて、「正は不正に譲歩しない」という根拠から違法性を阻却するのであるから、他に採るべき手段がないという言葉本来の意味で理解すべきでないが、正の立場の反撃者であっても、反撃のためならば何をやってもよいわけではなく、法秩序維持の見地から、①自己又は他人の権利を防衛するのに必要な範囲で、しかも、②できる限り法益侵害・危険の少ない手段を選ぶべきであるという考えに基づくものである。これを本記述についてみると、甲は、逃げ場がなかったことから、追い込まれた状態で、自己の身体の安全という重要な法益を保全するため（204条）、飼い主乙に対して犬をおとなしくさせるように申し向け、乙の意思決定の自由という身体の安全に比して軽い法益を侵害したものであるから、自己の権利を防衛する手段としての法益侵害・危険が最小限度のものであるという要件をみたすものと考えられる。よって、本記述における甲には、正当防衛が成立するから、脅迫罪は成立しない。

5 正しい

261条、37条1項。本記述では、甲がたまたま所持していたC所有の傘で犬を強打して怪我をさせるとともに、その傘を壊したものの（261条）であることから、防衛者が第三者の物を利用した場合の処理について問題となる。この点、甲の反撃行為は、乙の侵害に対する正当防衛としてなされたものであり、その行為の手段として正なるCの法益が侵害されたのであるから、甲とCは正対正の関係にあり、甲はCに対する関係ではその傘で現在の危険を回避したと考えることができ、緊急避難が成立する余地があると考えられる。そこで、本記述において緊急避難の成否を検討すると、「やむを得ずした行為」（37条1項）といえるかが問題となる。この点、「やむを得ずした行為」とは、法益保全のために唯一の方法であって、他に可能な方法がないという意味であると考えられる。これは、緊急避難は、正対正の関係を基礎とするから、無関係な第三者の法益を犠牲にできるのは、他に採るべき方法がない場合に限られるとする趣旨に基づくものである。これを本記述についてみると、甲は、逃げる余裕があったのにその場にとどまり、反撃行為に出たものであるから、法益保全のために他に可能な方法がないとはいえない。よって、本記述における甲には、緊急避難は成立しないことから、Cに対する関係で器物損壊罪が成立する。